



ADRIANA GABRIEL DOS SANTOS CADIMA

**Violação Digital dos Direitos Autorais:
A Internet e a Partilha de Conteúdos Protegidos
nas Redes P2P através do Protocolo Bittorrent**

*Dissertação de Mestrado em Direito, em Ciências Jurídico-Forenses, apresentada à
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sob a orientação do Professor Doutor
Alexandre Libório Dias Pereira*

Coimbra, Janeiro de 2015



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

teve-se em consideração que pertencendo ambos à União Europeia, se encontram sob o mesmo tecto conceptual (nomeadamente o das Ds. 2001/29 e 2000/31).

2.1 O Caso BTUGA

Portugal, apesar de territorialmente pequeno, já alberga uma sentença inédita. Essa sentença¹²⁸, de 1.^a instância, apesar de ainda não transitada em julgado (fruto da interposição de recurso¹²⁹) revela-se uma primeira abordagem directa a um problema crescente.

No dia 09 de Fevereiro de 2013, foi deduzida acusação contra um arguido: o fundador do serviço *on-line* de nome “Btuga”, correspondente ao (agora inexistente) sítio www.btuga.pt¹³⁰.

Após decisão instrutória¹³¹, o arguido foi pronunciado pela prática, em autoria material, de um crime de usurpação, previsto e punido pelos arts. 178.º, n.º1, als. A), 1.^a parte, c) e d), 184.º n.ºs 1 e 2, com referência aos arts.41 .º, n.º 2, 195.º, n.º 1, e 197.º, n.º 1, todos do CDADC.

Constituíram-se seis assistentes, entre eles a AUDIOGEST e a SPA¹³², deduzindo um pedido único de indemnização civil “peticionando com base nos factos daquela descritos, a condenação do arguido/demandado a pagar-lhes o valor correspondente ao preço das obras protegidas e que representam os respectivos direitos constantes de lista de *downloads* efectuada” (cerca de € 1 milhão) e a 2% do valor total do decréscimo de vendas que tiveram em resultado da sua conduta, por esse ser “o mínimo imputável ao *site* Btuga” (€ 180.000).

O arguido contestou, pedindo a sua absolvição uma vez que desconhecia os conteúdos partilhados no seu *site*, não tendo tido qualquer intervenção directa nessa

¹²⁸ A presente análise baseia-se na acusação deduzida e sentença proferida no processo n.º 1386/06.9JFLSB, a correr os seus termos no (antigo) 2.º Juízo Criminal de Lisboa, 3.ª Secção (agora Juiz 4), tendo aqueles elementos sido obtidos mediante requerimento a aquele processo.

¹²⁹ Informação obtida telefonicamente, por funcionário judicial, no dia 05-12-2014.

¹³⁰ Considerado o 3.º *site* mais acedido em Portugal.

¹³¹ Sobre a fase instrutória deste caso *vide* Alexandre D. Pereira, *Partilha de Ficheiros na Internet e Direito Autoral: Desenvolvimentos Legislativos e Jurisprudenciais na Europa*, in Revista da ABPI, n.º 123, Mar/Abr 2013, pp. 60 *et seq.*.

¹³² Sobre a questão específica de saber se a SPA se pode constituir Assistente em Processo Penal *vide* J. Oliveira Ascensão, *Direito Penal de Autor*, Coimbra Editora, 2001, pp. 499 *et seq.*.

partilha, uma vez que disponibilizar o *site* BTUGA não se trata de uma conduta criminalmente punível.

O serviço Internet BTUGA era acedível pelo endereço www.btuga.pt¹³³ e consistia numa rede (um “sistema”) de partilha de ficheiros P2P, assente no protocolo Bittorrent, dedicado à partilha de conteúdos fonográficos e videográficos, sem autorização dos respectivos titulares dos direitos de autor e dos direitos conexos.

De entre os factos provados, encontra-se a descrição da operação da partilha de ficheiros através das redes P2P utilizando o protocolo Bittorrent, bem como os respectivos conceitos¹³⁴.

Este serviço era limitado territorialmente a Portugal, ou seja, apenas utilizava tráfego português e apenas permitia que se acesse e utilizasse o serviço dentro da rede portuguesa.

A principal particularidade deste serviço é que, ao invés do que acontece com outros *sites*, para ser utilizado, o utilizador tinha de abrir os *torrents* através do *software* Btuga (também Bittorrent). Outra particularidade, agora relativa ao *software* propriamente dito, é que com a utilização deste, ao contrário do que acontece com a maioria dos programas construídos para esta finalidade, limitava¹³⁵ automaticamente o número de ficheiros que poderiam estar a realizar o *download* em simultâneo, sendo a forma de “desbloquear” este limite a subscrição de um serviço “PREMIUM”, mediante um pagamento de 5€/mês.

Os ofendidos/assistentes declararam que não autorizaram a colocação no serviço Internet Btuga daqueles conteúdos protegidos o que levou, no decorrer do processo, que tivesse ficado provado que com o sistema Btuga, o arguido lesou os titulares de todas as obras protegidas que foram partilhadas.

¹³³ O arguido criou e configurou o serviço BTUGA no ano de 2003, estando activo até 24-07-2007 (data da apreensão do material), sendo que a sua maior projecção decorreu entre 2006 e 2007.

¹³⁴ Cfr. *supra*, ponto 1, cap. II.

¹³⁵ Limites: Para receber 2 *torrents* tinha de semear pelo menos 1, para receber 3 tinha de semear pelo menos 2, sendo que era proibido receber mais do que 3 *torrents* em simultâneo.

2.1.1 Convicção do Tribunal

Aos olhos do Tribunal ficou provado que o serviço Btuga servia maioritariamente para a partilha de conteúdos protegidos, não tendo ficado provado quais conteúdos eram esses além de três¹³⁶, cujas cópias foram disponibilizadas por testemunhas inquiridas e cuja perícia foi efectuada.

Na verdade, na convicção do Tribunal, para que fosse possível identificar todos (ou diversos) conteúdos protegidos disponíveis no *site* Btuga (para além daquelas três obras) seria necessário que a prova tivesse sido produzida “quando o serviço se encontrava em pleno funcionamento” e, ainda, “a partir do momento e[m] que foi encerrado o serviço em questão a obtenção de tais elementos ficou impossibilitada.”. Esta derrapagem na produção de prova, na minha opinião, está intimamente relacionada com o facto de as nossas autoridades desconhecerem o como agir, como produzi-la, visto que estas situações se apresentam como uma completa novidade em termos judiciais.

2.1.2 Enquadramento Jurídico-Penal dos Factos Provados

Quanto ao enquadramento jurídico dos factos neste caso em concreto provados, o Tribunal referiu o art. 195.º (crime de usurpação) e o art. 199.º, o qual constitui uma situação delituosa derivada, *inter alia*, do crime constante no 195.º, i.e., o aproveitamento ilícito de uma obra usurpada¹³⁷, todos do CDADC. Também, foram referidos os arts, 68.º, n.º 2, 12.º, 28.º, 73.º, n.ºs 1 e 2, e, relativamente aos direitos conexos, foram referidos os arts. 176.º, 192.º, 178.º, 184.º e 189.º, todos do CDADC.

Quanto às utilizações livres, o Tribunal afirmou que “Apenas são lícitas as utilizações livres dessas obras devidamente elencadas no art. 75.º do código em referência, sendo que o regime de autorização para as restantes utilizações, previsto no art. 41.º do mesmo código, exige a formalidade escrita.”.

Da concatenação de todo o acervo legislativo agora indicado, o Tribunal concluiu que “perante o direito nacional assim constituído, independentemente de outras soluções legislativas existentes noutras legislações no âmbito do direito comparado que conduzam a soluções diversas (...), é a nossa lei que temos de aplicar, sendo manifesto que a mesma é

¹³⁶ Em causa estavam 772 torrents.

¹³⁷ Luiz Francisco Rebello, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos – Comentado*, Âncora Editora, 2002, p. 246.

em si abrangente não só para situações conhecidas como para outras que, eventualmente, não conhecidas aquando da elaboração da lei, tenham vindo ou venham a criar-se com os desenvolvimentos tecnológicos com que diariamente nos deparamos, sendo que a lei é, nos termos referidos, perfeitamente clara e, embora abrangente, suficientemente estanque de modo a que não se possa falar (...) em falta de tipicidade.”.

2.1.3 A não aplicação do regime da não responsabilização dos prestadores de serviços e a imputação concreta do crime ao agente em co-autoria

Perante a possibilidade de se aplicar a desresponsabilização dos prestadores de serviços, é necessário seguir de perto o disposto no DL n.º 7/2004, designadamente nos seus artigos 4.º, n.º 5 e 12.º.

Esta análise foi realizada perante o caso concreto Btuga, tendo o Tribunal concluído que o arguido, enquanto administrador e criador do *site*, não se limitou a disponibilizá-lo, tendo, ao invés tido uma participação activa “no processo de selecção de conteúdos a disponibilizar”, não lhe se poderá aplicar o regime de desresponsabilização relativo ao prestador de serviços, este sim abrangido por uma “desobrigação geral de vigilância”. *In casu*, “o arguido teve intervenção directa na escolha de conteúdos a disponibilizar para partilha” e uma vez que “a não obrigação geral de vigilância só tem aplicação quando tal não sucede (...), não podem subsistir dúvidas que o arguido preencheu objectiva e subjectivamente o tipo legal em questão, actuando embora em comunhão de esforços e, portanto, em co-autoria.”.

Na verdade, essa “co-autoria” é justificada com o facto de que “essa colaboração existiu, tendo o arguido o domínio do facto por ser o mesmo quem, tendo criado e disponibilizando o meio adequado para este tipo de partilha através da Internet, “autorizava”, como na prática sucedia, que os *torrents* novos cujo *upload* era efectuado por terceiros não concretamente identificados” ficando os conteúdos disponíveis “para o público em geral”.

Assim, e no entender do Tribunal os utilizadores que realizavam o *upload* dos *torrents* cometem o mesmo crime ora analisado, nada tendo sido referido aos utilizadores que apenas procedem ao *download*. Refira-se ainda que, é nesta sede que apenas se faz

uma breve alusão à disponibilização de conteúdos para o público em geral, não tendo o Tribunal abordado tal conceito nem as implicações (ou não) do mesmo.

Desta forma, o Tribunal entendeu ter o arguido cometido um crime de usurpação, previsto e punido nos artigos 195.º, n.º 1 e 197.º, ambos do CDADC¹³⁸.

Aquando da determinação da pena, o Tribunal considerou as necessidades de prevenção geral medianas, atendendo à “frequência com que vêm sendo cometidos crimes de natureza idêntica à do crime ora em apreço” e, ainda “o facto de estas condutas não causarem grande alarme social”.

2.1.4 Análise do Pedido de Indemnização Civil

Quanto à análise do PIC deduzido, bem como ao método aplicado para o alcance do valor nele constante, o Tribunal decidiu não considerar assente qualquer lista que correspondesse a obras concretas protegidas, não tendo por assente também que o respectivo valor dessas obras partilhadas correspondesse ao valor peticionado¹³⁹.

No que toca aos danos patrimoniais peticionados, há uma referência ao Acórdão do TRL, já *supra* referido¹⁴⁰, considerando-se reproduzido o que *supra* se expôs. Assim, e à luz da conclusão que a existência desses produtos usurpados não implica, necessariamente, para a esfera patrimonial dos titulares dos direitos¹⁴¹, a existência de qualquer dano (prejuízo), o Tribunal declarou o PIC improcedente. Também, não tendo sido provado que (1) existiu um decréscimo de vendas e que (2) esse decréscimo fosse imputável à existência do *site* Btuga, foi também declarado improcedente o PIC quanto ao pedido de 2% relativo ao decréscimo nas vendas. Foi ainda afirmado, não se ter logrado provar que o valor ganho pelo arguido através da existência do serviço “Premium” se devesse à partilha de conteúdos protegidos acrescentando-se, ainda, que os únicos três conteúdos considerados nesta sentença, não foram partilhados mediante a utilização de tal serviço. Ainda numa última análise quanto a uma eventual compensação pelos danos, o Tribunal considerou a possibilidade facultada pelo art. 211.º, n.º 5, do CDADC de ser

¹³⁸ A pena concreta aplicada ao arguido foi uma pena de prisão de 8 meses (substituída por uma pena de multa de 230 dias) e 190 dias de multa, o que correspondeu, em cúmulo material, a uma pena única de 420 dias de multa, à razão diária de € 30.

¹³⁹ Vide ponto 3.2, Cap. II.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Id.*

fixado um valor, mas que tal não foi peticionado em nenhum momento processual. Mesmo que se considerasse viável a aplicação desta última faculdade, considerando que o PIC foi deduzido de uma forma global e que não foram provados danos referentes a cada uma das demandantes, não poderia o Tribunal atribuir um valor global.

Em suma, foi o arguido absolvido do peticionado pelas demandantes tendo ainda sido ordenada a devolução da quantia apreendida ao arguido (ou seja, o que este alegadamente recebeu a título da subscrição, por parte dos utilizadores, do serviço “Premium”).

2.1.5 Comentário

Num caso que culminou com uma condenação concreta de um indivíduo por um crime de usurpação através da disponibilização de um serviço partilha de conteúdos protegidos na Internet, nos termos *supra* expostos, retira-se a conclusão que, tendo sido a conduta criminalizada com o escopo de proteger a esfera patrimonial dos titulares de direitos de autor, esses mesmos titulares, cujos interesses a lei tenciona proteger, viram os seus interesses e petições despidos de qualquer tutela, não tendo sido, apesar de todas as diligências que levaram a cabo, compensados por quaisquer alegados danos (prejuízos e lucros cessantes) sofridos.

Também, na minha opinião, um dos pontos criticáveis na sentença ora em apreço é o parco fundamento teórico que não se mostrou suficientemente aprofundado e esclarecido.

Por outro lado, baseado na falta de prova, paira na sentença a conclusão de, se por um lado ficou provado que a conduta do arguido lesou os titulares dos direitos relativos aos conteúdos protegidos partilhados, por outro, tal prova não se logrou suficiente para culminar numa obrigação de indemnizar tais titulares. Cumpre-nos perguntar, então, como se lograria alcançar tal prova que se mostrasse suficientemente *palpável* para que fosse possível a atribuição de tal indemnização? E ainda, se essa prova fosse possível, após, como seria possível provar (ou até o Tribunal fixar arbitrariamente) um valor para essa indemnização? Ao ler a sentença, as respostas a tais perguntas permanecem ausentes.

Por fim, não se compreende, à luz da fundamentação apresentada na sentença, a ausência de referência à instigação de colocação de conteúdos protegidos à disposição do

público em geral – questão que tem sido colocada e apreciada em casos análogos. De facto, tal instigação pode ser retirada, desde logo, dos limites impostos pelo *software* utilizado neste serviço, ou seja, na imposição de os utilizadores, para terem acesso aos conteúdos desejados, terem, também, de disponibilizar conteúdos. Assim, se, por exemplo, se entendesse, tal como entendeu o MP¹⁴², que a conduta traduzível pelos utilizadores procederem apenas ao *download* de conteúdos, poder consubstanciar-se numa actividade *lícita*, por exemplo, ao abrigo das disposições referentes às utilizações privadas, *maxime* a cópia privada, tal conduta passaria a ser *ilícita* devido à imposição de tal colocação à disposição do público. Acrescente-se que tal falta de referência não é compreensível, também, face ao facto de ter ficado explicitamente provado que o arguido, na qualidade de criador e gestor do serviço, *encorajava* a partilha de ficheiros, obtendo, ainda, recursos económicos (provenientes do serviço “Premium” e ainda de receitas publicitárias) para tal serviço. Assim, demonstro tal incompreensão.

2.2 O Caso THE PIRATE BAY

2.2.1 Generalidades

Neste momento, e considerando o exposto sobre a sentença portuguesa do caso Btuga, importa agora, como objectivo complementar, analisar a sentença que reporta ao caso The Pirate Bay¹⁴³ (sendo este estruturalmente equiparável ao sistema apresentado no Btuga).

Na última década, o TPB tem sido considerado um dos maiores *sites* permissivos da partilha de ficheiros nas redes P2P através do protocolo Bittorrent, tendo-se tornado, assim, o logótipo da partilha de ficheiros (com conteúdos protegidos, ou não¹⁴⁴) *online*.

No dia 16 de Dezembro de 2014, o TPB, no seu *site*, mostrava que tinha mais de 6 milhões e meio de utilizadores registados e mais do que 40 milhões e meio de *peers*¹⁴⁵, ou seja, cerca de 47 milhões de utilizadores, o que corresponde a cerca de 4 vezes mais a

¹⁴² Vide ponto 5., parte II, cap. III.

¹⁴³ Vamos seguir o constante da sentença condenatória n.º B 13301-06 que correu os seus termos no *Stockholm District Court*, na Suécia, de 17-04-2009 (disponível em <http://www.ifpi.org/content/library/Pirate-Bay-verdict-English-translation.pdf> - último acesso: 27-01-2015)

¹⁴⁴ O foco aqui será o material disponibilizado ilicitamente por ser material protegido por direitos de autor e o facto de ser disponibilizado sem a obtenção do devido consentimento.

¹⁴⁵ Dados obtidos através da visita ao *site* www.thepiratebay.cr.